

0010502-13.2017.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0010502-13.2017.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 354/2017 - 7º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Fernando de Freitas Cordeiro

Vítima:

GILBERTO MESSIAS DO NASCIMENTO e outro

Artigo da Denúncia:

*

Aos 21 dias do mês de novembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o Defensor Público, Dr(a). Rafael Alvarez Moreno.

Ausente o acusado CARLOS FERNANDO DE FREITAS CORDEIRO, que encontra-se evadido do CDP, onde cumpria regime semiaberto, conforme pesquisa VEC de fls.261.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista a ausência do réu e o teor da certidão supra, DECRETO A REVELIA do réu.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, CARLOS FERNANDO DE FREITAS CORDEIRO, qualificado nos autos, está sendo regularmente processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal porque, em data não apurada, no período entre 22 de fevereiro e 18 de abril de 2017, nesta

cidade e Comarca de Piracicaba, adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular, marca Motorola, G1, IMEI 354989052613748, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), que sabia ser produto de crime pertencente a Gilberto Messias Nascimento.

A denúncia foi recebida a fls. 205/206. O réu foi citado (fls. 212/213) e a Defensoria Pública apresentou defesa prévia (fls. 217/218).

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através dos boletins de ocorrência (fls. 05/08 e 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), e Auto de Avaliação Indireta (fls. 83).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, no dia 22 de janeiro de 2017, nesta cidade foi subtraído o aparelho celular Motorola, G1, IMEI 354989052613748, pertencente à vítima Gilberto Messias Nascimento (cf. RDO 269550, fls. 17/18).

No dia 18 de fevereiro de 2017, policiais militares passavam pela rua das Castanheiras, bairro Bosque dos Lenheiros, quando avistaram e suspeitaram do denunciado. Feita abordagem de praxe, em poder dele foi localizado o aparelho celular subtraído.

Instado, ele alegou que havia adquirido o aparelho celular de uma pessoa de prenome "Douglas", morador do bairro Bosque dos Lenheiros e em troca teria dado um televisor.

Assim, restou demonstrado que o denunciado sabia que se tratava de produto de crime, tanto que não comprovou a posse lícita, não comprovou o pagamento pela aquisição e não indicou a identidade do vendedor.

Com efeito, em solo policial, a vítima Gilberto Messias Nascimento, declarou que estava com sua esposa em uma área verde, próxima à sua residência, logo após terem chegado em casa, por volta de 20h00, quando notaram a aproximação de dois sujeitos, os quais os abordaram e determinaram a entrega dos aparelhos celulares. Disse que um dos sujeitos estava encapuzado e tinha arma de fogo. O outro estava de "cara limpa", mas em razão de estar escuro no momento, não tem condições de realizar o reconhecimento fotográfico. O aparelho celular subtraído era um Motorola, modelo G1, avaliado em R\$ 700,00. Após pegarem os celulares, os mesmos indivíduos se aproximaram de uma senhora que passava pelo local e subtraíram dela a bolsa que carregava, fugindo em direção à avenida Alberto Vollet Sachs (fls. 50).

Em juízo, a vítima ratificou as declarações e acrescentou que além do seu aparelho celular foi subtraído o aparelho de sua esposa também. Depois de algum tempo foi chamado à delegacia de polícia e recuperou seu aparelho celular. Não sabe como foi apreendido.

A esposa da vítima, Maurília de Fátima Silveira Nascimento, narrou que estava com o marido em uma área verde, próxima à sua residência, por volta de 20h00, quando notaram a aproximação de dois sujeitos, os quais os abordaram e determinaram a entrega dos aparelhos celulares. Disse que ambos aparentavam ser de cor preta, um mais alto que o outro. O mais alto estava encapuzado e tinha uma arma de fogo. Após pegarem os celulares, os mesmos indivíduos aproximaram-se de uma senhora que passava pelo local e subtraíram dela a bolsa que carregava, fugindo em direção à avenida Alberto Vollet Sachs. O aparelho celular subtraído era um Motorola, modelo G3 plus, com valor estimado de R\$ 900,00 (fls. 49).

Na fase inquisitorial o policial militar Mário Alessandro Camolesi declarou que no dia 18/04/2017 estava em patrulhamento na rua das Castanheiras, próximo ao numeral 184, bairro Bosques dos Lenheiros, quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Realizada a busca pessoal, com ele fora encontrado um aparelho celular da marca Motorola. Na sequência, constataram junto ao COPOM o IMEI do aparelho e receberam a informação de que era produto de roubo, objeto do Boletim de Ocorrência 269550/2017, em 23/02/2017. Indagado, o acusado disse que tinha adquirido o aparelho há 2 meses em uma negociação (fls. 51).

Em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase policial.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Diego Lázaro de Freitas (fls. 52).

Em juízo, Diego ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Em solo policial, o réu negou a prática do delito, afirmando que havia comprado o aparelho "de segunda mão (fls. 121).

Em juízo foi decretada a revelia do réu.

Assim, restaram indúvidas autoria e materialidade delitivas.

Ademais, não há nada nos autos que desmereça as declarações da vítima, o depoimento da testemunha e dos policiais militares, os quais são esclarecedores e levam à culpabilidade do réu.

Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais militares são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho:

O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Ainda nesse sentido:

PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei).

Restou demonstrado que o denunciado sabia que se tratava de produto de crime, tanto que não comprovou a posse lícita, não comprovou o pagamento pela aquisição e não indicou a identidade do vendedor.

Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor.

Seguindo o critério trifásico, na primeira fase deve ser aplicada pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes.

Na segunda fase, a pena deve ser exasperada em razão da reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, em razão da reincidência e maus antecedentes.

Pelo mesmo motivo, vedada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos sobreditos termos.

Dada a palavra ao nobre defensor do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Carlos Fernando de Freitas Cordeiro foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo denúncia (fls. 201-203), no período entre 22 de fevereiro de 2017 a 18 de abril de 2017, nesta cidade e Comarca, Carlos adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular, marca Motorola, G1, IMEI 354989052613748, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), que sabia ser produto de crime, pertencente a Gilberto Messias Nascimento.

Ainda conforme a inicial acusatória, no dia 22 de janeiro de 2017, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, foi subtraído o aparelho celular (cf. RDO 269550, fls. 17/18). No dia 18 de fevereiro de 2017, policiais militares passavam pela rua das Castanheiras, bairro Bosque dos Lenheiros, quando avistaram e suspeitaram do denunciado. Feita abordagem de praxe, em poder dele foi localizado o aparelho celular subtraído. Instado, ele alegou que havia adquirido o aparelho celular de

uma pessoa de prenome "Douglas", morador do bairro Bosque dos Lenheiros e em troca teria dado um televisor. Assim, segundo a acusação, restou demonstrado que o denunciado sabia que se tratava de produto de crime, tanto que não comprovou a posse lícita, não comprovou o pagamento pela aquisição e não indicou a identidade do vendedor.

Na delegacia, o policial militar Mario Alessandro Camolesi disse que: "estava em patrulhamento pelo local dos fatos quando deparou com um indivíduo em atitude suspeita; de imediato, foi abordado e durante revista pessoal foi localizado em sua posse um aparelho celular marca Motorola; posteriormente foi verificado junto ao Copom seus

antecedentes criminais, não constando nenhuma pendência com a Justiça; porém, ao ser verificado o IMEI do referido aparelho, constou ser subtraído; indagado ao mesmo sobre a procedência do aparelho celular informou que o adquiriu há 2 meses, em uma negociação; lidos seus direitos constitucionais e encaminhado ao plantão policial, sendo realizado registro de boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica do referido aparelho n.o 269550/2017, em 23.02.2017, por roubo; não conhecia o investigado antes dos fatos" (fls.51)

No mesmo sentido as declarações do policial militar Diego Lazaro de Freitas. (fls.52)

Na delegacia a vítima Gilberto Messias Nascimento disse que: "na data dos fatos, havia acabado de chegar em casa, com sua esposa, e resolveram ir passear com a cachorra, defronte a sua casa, onde há uma área verde e uma academia para idosos; era por volta das 20h00, quando notaram a presença de dois indivíduos, ambos de cor preta, sendo que se aproximaram e disseram: "Vocês perderam"; o declarante estava com seu aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G 1, avaliado em 700 reais, bem como sua esposa também trazia seu celular consigo; imediatamente os indivíduos retiraram os objetos, sendo que o celular dela estava caído no chão, atrás do banco onde estavam sentados; assim que pegaram os aparelhos, notaram a presença de uma senhora, que passava ali no momento, sendo que o que estava armado, usava capuz e tratava-se de uma arma de cor preta, este ficou ali rendendo o declarante e sua mulher: o outro, se aproximou da senhora e também roubou-a, levando sua bolsa; não sabe dizer nome dessa senhora, apenas que mora nas imediações, mas ela não quis registrar ocorrência; não sabe dizer o que foi levado dessa senhora; assim que pegaram o que queriam, os autores desceram correndo para a direção da avenida Professor Alberto Vollet Sachs; não tem condições de fazer reconhecimento fotográfico ou pessoal, apesar de um deles estar de "cara limpa; não ficaram machucados." (fls.50)

No mesmo sentido as declarações da vítima Maurilia de Fátima Silveira Nascimento (fls. 49)

Interrogado em solo policial, o acusado disse que: "Que referente ao aparelho de celular que se encontrava em sua posse durante a abordagem dos policiais, há dois meses tinha

comprado o mesmo de "segunda mão". Que não se recorda do nome de quem lhe vendeu o referido aparelho." (fls. 107)

Às fls. 181-184 juntada certidão de objeto e pé do acusado que indica seus maus antecedentes (0003408-97.2006.8.26.0451, art. 155, trânsito em julgado para o réu em 28/11/2008; 0027204-20.2006.8.26.0451, art.155, trânsito em julgado para o réu em 10/09/2012) e reincidência (0010898-05.2008.8.26.0451, art. 33, LD, pena cumprida em 11/03/2016; 0016629-11.2010.7.26.0451, art. 155, pena cumprida em 11/03/2016; 0025927-37.2004.8.26.0451, art. 157, 11/03/2016).

Durante a instrução, foram colhidos os seguintes elementos probatórios:

a) Inicialmente, ouvido Gilberto Messias Nascimento, proprietário do telefone celular. No dia da subtração, estava em frente de casa, aproximaram-se 2 indivíduos "de cor", não se recorda de mais nenhuma descrição porque estava escuro. Ele e a esposa foram rendidos e roubaram os 2 aparelhos de telefone celular. Fez boletim de ocorrência. Não recorda quanto tempo se passou até o seu telefone ser recuperado, de 5 a 6 meses. Foi contatado pelos policiais civis. Foi à delegacia e recuperou o seu aparelho celular. O celular da esposa não foi recuperado. Não conseguiria reconhecer a pessoa que subtraiu o celular.

b) Em seguida, ouvido o policial Diego Lazaro de Freitas. Fizeram uma abordagem e investigaram o IMEI do aparelho que a pessoa portava. Viram que era fruto de roubo. Ele disse o apelido da pessoa de quem adquiriu o aparelho. Trocou por uma televisão. A abordagem ocorreu pela atitude, o indivíduo apresentou “certo nervosismo” quando viu a viatura e mudou de direção repentinamente. Estava sozinho.

c) Na sequência, ouvido o policial militar Mario Alessando Camolesi. Estavam em patrulhamento pelo bairro Bosque dos Lenheiros. Viram um indivíduo que demonstrou nervosismo e mudou o caminho para o qual se dirigia (fundada suspeita). Consultaram o IMEI do aparelho celular do indivíduo via COPOM e constataram que se tratava de aparelho objeto de crime. O réu passou características da pessoa de quem adquiriu o aparelho, há aproximadamente 2 meses, mas não sabia o nome. Não indicou onde a pessoa poderia ser localizada. Disse que trocou o aparelho de celular por um aparelho de TV. Não conhecia o réu. Ele estava sozinho. Consultada a sua ficha criminal, viram que nada devia. Sobre o acesso ao celular, faz muito tempo, não se recorda se ele permitiu o acesso, mas geralmente as pessoas permitem, pois não devem nada. O IMEI pode ser localizado no aparelho, abrindo-se a capa de trás e retirando a bateria, ou acessando as configurações.

d) Por fim, não foi efetuado o interrogatório do acusado, visto que ele se encontra evadido do sistema prisional.

Absolvição. Ausência de dolo. Desclassificação para modalidade culposa: Afastada a argumentação acima exposta, impõe-se a absolvição do imputado. Isso porque não foi produzido em juízo nenhum elemento de prova que indique que o réu tenha praticado algum dos verbos nucleares do tipo do art. 180 do CP. Assim, a conduta a ele imputada é atípica.

Como se não bastasse, infere-se dos elementos de prova que o réu não atuou com dolo direto. Com efeito, nenhum dos elementos de prova apontam que o réu, de fato, tinha consciência da origem ilícita do celular. Por via de consequência, não é possível concluir que agiu com dolo direto. E, assim, a sua conduta não se amoldou ao tipo do art. 180, caput, do CP, eis que esse exige dolo direto. Por isso, de rigor a absolvição, na forma do art. 386, III, do CPP, ou a descclassificação para a forma culposa.

Absolvição. Ilícitude probatória. Abordagem pautada em simples atitude suspeita: Ademais, no caso sub examine, é de rigor que seja declarada a absolvição por ausência de prova da materialidade do delito (CP, art. 386, II ou V), tendo em vista a ilicitude probatória decorrente da desvirtuada atuação dos policiais militares (CF, art. 5º, LVI, c. c/ art. 157 do CPP).

Conforme descrito na denúncia e informado em juízo, a apreensão do aparelho celular foi efetuada por policiais que decidiram pela abordagem porque o réu, ao avistar a viatura, teria demonstrado certo nervosismo. Como se percebe, a abordagem e a busca pessoal que a seguiu foram pautadas em critérios meramente subjetivos. Ocorre que, como sabido, a busca pessoal não pode ser realizada sem a presença de fundadas razões que a justifiquem.

O CPP, art. 244, a esse propósito, dispõe que: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (grifos nossos). A “fundada suspeita”, como é fácil concluir, constitui conceito extremamente vago e genérico, sendo difícil sua delimitação no caso concreto. O fato, no entanto, é que a Constituição Federal e os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos protegem o cidadão contra detenções arbitrárias – e a busca pessoal, ainda que não resulte na apreensão de objetos ilícitos, acarreta momentaneamente a detenção do indivíduo.

Nesse ponto, rememore-se que o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, prescreve que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (grifos nossos). Em sentido aproximado, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7.3 prescreve que “Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários” (grifos nossos). Já o art. 9.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos

estipula que "Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos" (grifos nossos). Perceba-se, por conseguinte, que o ordenamento nacional protege o jurisdicionado contra detenções arbitrárias, estabelecendo que alguém somente poderá ser detido em conformidade as hipóteses previstas em lei.

O Supremo Tribunal Federal, nessa linha de raciocínio, já decidiu que "A 'fundada suspeita', prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter por configurados na alegação de que trajava, o paciente, um 'blusão' suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder".

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por seu turno, já proferiu decisão no sentido de que "Em razão da ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece a convicções pessoais dos agentes intervenientes e a práticas dos próprios órgãos de segurança, os quais comportam um grão de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da Convenção Americana.

Adicionalmente, quando essas convicções ou apreciações pessoais sejam formuladas com amparo em preconceitos ou características ou condutas supostamente próprias de determinada categoria ou grupo de pessoas ou em relação ao seu status social-econômico, poderá ocorrer uma violação ao disposto nos arts. 1.1 e 24 da Convenção. [...]. O uso desses perfis supõe uma presunção de culpabilidade contra toda pessoa que neles se encaixe, e não a avaliação casuística sobre as razões objetivas que efetivamente indiquem que uma pessoa está vinculada ao cometimento de algum delito".

Necessário frisar, ainda, que, diante da seletividade que caracteriza o sistema punitivo, as abordagens costumeiramente se direcionam a pessoas negras ou pardas, assim como são efetuadas em locais caracterizados por altos índices de exclusão social, o que viola o princípio da igualdade (CF, art. 5º) e caracteriza racismo estrutural.

Não por outro motivo, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça definiu que "O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata". Com isso, "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP".

Ademais, "O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida". Por via de consequência, "A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

Se é assim, no caso em exame, a busca pessoal não poderia ter sido realizada, eis

que pautada na simples "atitude suspeita", não havendo qualquer elemento concreto que justificasse a invasiva medida e não se tornando válida pelo fato de que o aparelho telefônico foi encontrado em poder do acusado.

Isso posto, o auto de apreensão, não obstante ateste a materialidade do delito, é oriundo de uma ilicitude (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157) e, por isso, imprestável para a formação do convencimento judicial. Sendo assim, impõe-se o seu desentranhamento dos autos (CPP, art. 157, caput) e, por via de consequência, resta afastada a materialidade do delito, motivo pelo qual a absolvição se torna imperiosa (CPP, art. 386, II e V).

Alegações relativas à dosimetria da pena: Na remota hipótese de condenação, no que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nota-se que o acusado ostenta maus antecedentes, devendo essa circunstância ser dinamizada no patamar máximo de 1/6.

todavia, será de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior. Na segunda fase, igualmente, a agravante da reincidência deve ser dinamizada no patamar máximo de 1/6. Não há, por outro lado, circunstâncias a serem apreciadas na terceira etapa de dosimetria.

Regime inicial de cumprimento de pena: No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso. É certo, ademais, que, conforme se infere da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, por si só, não pode justificar a escolha do regime mais gravoso para o caso. Pugna-se, assim, pela fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto.

Não condenação em custas: E, por fim, em caso de procedência, postula-se seja suspensa a exigibilidade da condenação em custas (CPC, art. 98, § 3º, c. c/ art. 3º do CPP), tendo em vista que o acusado é assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se, pois, sua hipossuficiência econômica.

Em seguida pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

CARLOS FERNANDO DE FREITAS CORDEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 180, caput, do Código Penal, porque em data não apurada, no período entre 22 de fevereiro de 2017 a 18 de abril de 2017, nesta cidade e Comarca, adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular, marca Motorola, G1, IMEI 354989052613748, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), que sabia ser produto de crime pertencente a G.M.N.

Segundo a denúncia, no dia 22 de janeiro de 2017, nesta cidade foi subtraído o aparelho celular Motorola, G1, IMEI 354989052613748, pertencente à vítima G.M.N. (RDO 269550, fls. 17/18).

No dia 18 de fevereiro de 2017, policiais militares passavam pela Rua das Castanheiras, bairro Bosque dos Lenheiros, quando avistaram e suspeitaram do denunciado. Feita abordagem de praxe, em poder dele foi localizado o aparelho celular subtraído.

Instado, ele alegou que havia adquirido o aparelho celular de uma pessoa de prenome "Douglas", morador do bairro Bosque dos Lenheiros e em troca teria dado um televisor.

Assim, restou demonstrado que o réu sabia que se tratava de produto de crime, tanto que não comprovou a posse lícita, não comprovou o pagamento pela aquisição e não indicou a identidade do vendedor.

A denúncia foi recebida (fls. 205/206), o réu citado (fls. 213), apresentando resposta escrita, na qual se reservou o direito de discutir suas teses em momento posterior à instrução probatória (fls. 217/218).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 220/222).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns (fls. 248/249), sendo decretada a revelia do réu que se evadiu do sistema penitenciário (fls. 261), depois de ter sido intimado da audiência (fls. 260).

Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública pleiteou a desclassificação para a conduta culposa, alegando a ilicitude da prova, em razão da abordagem sem justificativa.

É o relatório.

DECIDO.

I – Da preliminar

Alegou a Defensoria Pública que a prova é nula, na medida em que os policiais militares não poderiam abordar o réu, sem que houvesse suspeita na sua conduta. Ocorre, contudo, que os policiais militares suspeitaram do réu, porque ele desviou sua direção, ao avistar a viatura e, tendo em vista que o ele se encontrava em via pública, ele foi abordado.

E mais, tratando-se de abordagem na via pública, há entendimento jurisprudencial no sentido da desnecessidade de justa causa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por policiais militares quando, ao avistar os agentes, correu para dentro de sua residência. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 3. "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial" (REsp 1.574.681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017). 4. No caso, o ingresso dos policiais na residência do Paciente foi amparado tão somente no fato deste ter adentrado rapidamente em sua residência ao avistar os agentes, o que por si só não caracteriza elemento objetivo apto a legitimar a medida. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.352/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022) – grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. FUGA DO AGENTE E DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 2. "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial (HC n. 415.332/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/8/2018). 3. Hipótese em que a simples fuga do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 132.343/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021) - grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE

DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. (...) 12. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial. (...) 15. Recurso provido, ex officio, para reconhecer, nos Autos n. 0024.19.100.161-9, a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP, determinando, assim, a sua imediata soltura. (RHC 118.817/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, bem como pelo auto de avaliação de fls. 83, segundo o qual o celular tem valor de R\$ 700,00.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase investigativa, o réu afirmou que se encontrava na posse do aparelho celular, durante a abordagem dos policiais. Há dois meses tinha comprado o aparelho de "segunda mão". Não se recorda do nome de quem lhe vendeu o referido aparelho (fls. 107). Em novo interrogatório, o réu permaneceu em silêncio (fls.141).

Em Juízo, o réu tornou-se revel.

Suas alegações, no entanto, não encontram amparo nos demais elementos de prova. Vejamos.

A vítima G.M.N. declarou que dois celulares foram subtraídos e só acharam o dele. Estava na frente de casa, quando dois rapazes se aproximaram e renderam ele e a esposa, roubando os dois celulares. Fez o boletim de ocorrência. Depois de 05 ou 06 meses, seu celular foi recuperado. Os policiais ligaram para ele e, na Delegacia, conseguiu recuperar o celular. Não sabe como o celular foi recuperado. O celular de sua esposa não foi recuperado. Não viu a pessoa com quem o celular foi recuperado e não conseguiria reconhecer os roubadores (fls. 248/249).

Mario Alessandro Camolesi, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro Bosque dos Lenheiros, quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, mudando a direção, quando viu a viatura. Ele foi abordado e, em revista, encontraram apenas o celular. Indagado sobre a procedência do celular, ele não sabia dizer. Pesquisado pelo EMEI, conseguiram saber que havia queixa de roubo com relação ao celular. O réu não tinha problema com a Justiça. Ele disse que havia trocado o celular com uma TV, há 02 meses, mas não soube informar o nome da pessoa que fez a troca, passando apenas as características físicas. O réu não falou onde poderia ser localizada a pessoa que trocou o celular com ele. Não conhecia o réu. O aparelho era um Motorola. O réu estava sozinho. Conseguiram o EMEI, no próprio aparelho ou quando ele foi destravado. Normalmente, as pessoas liberam o celular, mas nesse caso, não soube dizer, em razão do tempo (fls. 248/249).

O também policial militar Diego Lázaro de Freitas asseverou que realizaram uma abordagem no bairro e, em revista pessoal no indivíduo, encontraram apenas um celular. Pesquisaram o celular e tratava-se de produto de crime anterior. O réu falou que tinha adquirido o celular numa negociação, 02 meses antes. Segundo o réu, ele teria trocado o celular por um TV, de pessoa que só sabia pelo apelido e não identificou, nem soube descrever. O réu, para ser abordado, apresentou certo nervosismo, mudando de direção e, por isso, foi abordado. Pelo que se recorda, o réu estava sozinho, quando abordado. Não conhecia o réu (fls. 248/249).

No que se refere à receptação, está ela comprovada, porquanto o bem foi roubado (boletins de ocorrência de fls. 05/08 e 20/21) e, posteriormente, localizado na posse do réu (auto de exibição e apreensão de fls. 14/15).

Resta saber se o réu tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular.

O elemento subjetivo, porque interno, deve ser apreciado diante das circunstâncias objetivas e externas e conduzem à convicção de que o réu tinha conhecimento da

origem espúria do aparelho celular.

Alega o réu que trocou um televisou pelo aparelho celular com um sujeito chamado Douglas, morador do Bosque dos Lenheiros, conforme consta no boletim de ocorrência de fls. 11/12. Inclusive, o setor de investigação tentou a localização de Douglas, mas não foi possível identificá-lo, exatamente por ausência de elementos trazidos pelo próprio réu (fls. 32).

Ocorre, no entanto que, em interrogatório policial, o réu disse que comprou o celular, não se recordando do nome do vendedor, que não conseguiu identificar (fls. 107).

Ademais, o réu não forneceu nota fiscal ou qualquer outro documento que justificasse a posse do bem.

O réu também não trouxe aos autos o comprovante de pagamento.

Com efeito, esses elementos são suficientes para a certeza de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho.

Diz a jurisprudência:

Apelação criminal. Receptação dolosa e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos crimes bem comprovadas. Negativa do réu refutada pelas demais provas. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do automóvel, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Crime de trânsito também evidenciado. Condenação mantida. Penas dosadas sem excesso. Recurso não provido, com anotação. (TJSP; Apelação Criminal 0001735-50.2016.8.26.0635; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).

RECEPTAÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - DOLO EVIDENCIADO - PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0011016-68.2018.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).

Receptação - Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Privilégio descabido - Pena e regime fixados com correção - Restrição da pena substitutiva à prestação de serviços à comunidade - Inteligência do § 2º do artigo 44 do Código Penal - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0002785-42.2017.8.26.0291; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).

De outro lado, verifica-se que o réu foi abordado na posse do bem e, portanto, cabia a ele o dever de comprovar a aquisição lícita do celular.

Nesse sentido:

Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recurso do Ministério Público. Autoria que se comprova por meio da posse de celular objeto de roubo precedente, cabendo ao possuidor demonstrar a licitude de sua posse, ônus do qual o apelado não se desincumbiu. Condenação pela receptação, impondo-se a pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 10 dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0037404-08.2018.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO (Artigo 180, "caput", do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO - INADMISSIBILIDADE -

MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Pena-base fixada no mínimo legal e manutenção do regime inicial semiaberto - Recorrente reincidente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0043328-97.2018.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1244089/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CP. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DISPOSITIVO QUE NÃO POSSUI COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. CORTE LOCAL QUE ASSEVERA EXISTIR PROVA A AMPARAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. ALTO VALOR ECONÔMICO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA A SER CONSIDERADA DESFAVORAVELMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. INTENSIDADE DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER VALORADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IN CASU, HÁ ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INTENSIDADE DO DOLO.

PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Alegação de inexistência de prova a sustentar a condenação. Dispositivo que não possui comando normativo suficiente para infirmar o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF. 1.1. Ainda que assim não fosse, a Corte local asseverou existir prova a amparar o juízo condenatório. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 1.2. Ademais, "a conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (HC 433.679/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018). 2. Em relação ao questionamento sobre a aplicação do preceito secundário previsto no § 1º do art. 180 do CP: "não se mostra prudente a imposição da pena prevista para a receptação simples em condenação pela prática de receptação qualificada, pois a distinção feita pelo próprio legislador atende aos reclamos da sociedade que representa, no seio da qual é mais reprovável a conduta praticada no exercício de atividade comercial" (EResp 772.086/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 11/4/2011). 3. O alto valor econômico do bem pode ser considerado desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 4. "A intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao juízo de reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda" (HC 173.864/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 03/03/2015; HC 171.395/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2011)" (HC 256.366/RJ, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSC), QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015). 4.1. Na hipótese em foco, o acórdão

condenatório asseverou que o réu "é comerciante da área há aproximadamente 20 anos, e dele se exige a devida cautela, verificando a procedência dos bens e analisando a sua nota fiscal, antes de determinar a entrega em seu estabelecimento". Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade quanto à adjetivação negativa pela intensidade do dolo, pois foi traçada fundamentação concreta a justificar o desvalor da culpabilidade. 5. Questionamento quanto à proporcionalidade da exasperação da pena: "não é possível mensurar, matematicamente, o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido" (AgRg no HC 309.253/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 8/3/2018). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RESp 1529699/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018 - grifei).

Caracterizado está, pois, o dolo do agente, sendo impossível a desclassificação pretendida pela Defesa.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, a condenação do réu é de rigor, sem se falar em falta de provas para o conjunto probatório.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu possui antecedentes criminais (Certidão de fls. 183 - Processo nº 000548-74.2016.8.26.0451; Certidão fls. 183 - Processo nº 0000858-872017.8.26.0599; Certidão de fls. 183/184 - Processo nº 0003408-97.2006.8.26.0451; Certidão de fls. 184 - Processo nº 0005368-39.2016.8.26.0451; Certidão de fls. 186/187 - Processo nº 0027204-20.2006.8.26.0451 e Certidão de fls. 191 - Processo nº 0073836-12.2003.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa.

A multirreincidência (Certidão de fls. 185 - Processo nº 0010898-05.2008.8.26.0451; Certidão de fls. 185/186 - Processo nº 0016629-11.2010.8.26.0451; Certidão de fls. 186 - Processo nº 0025927-37.2004.8.26.0451 e Certidão de fls. 190 - Processo nº 0067719-05.2003.8.26.0451, cujas penas foram extintas em 2016) trará novo aumento de um sexto à pena: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias e 12 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, diante dos maus antecedentes e da reincidência, já que demonstrado que as penas anteriores não foram suficientes para afastá-lo da delinquência.

Pena final: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR CARLOS FERNANDO DE FREITAS CORDEIRO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente não específico e portados de péssimos antecedentes, de forma que não é adequada a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, porque não traria o efeito de evitar novas práticas delitivas. Ressalto, outrossim, que o réu cumpria pena em regime semiaberto e, atualmente, encontra-se evadido.

O réu encontra-se em liberdade e assim deverá permanecer caso deseje recorrer desta sentença.

Justiça Gratuita já concedida.

Custas na forma da lei.

Pela defensora foi requerido vista dos autos após a intimação do réu do teor da r.sentence.

Pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Defiro o requerido, devendo a serventia providenciar a vista dos autos à Defensoria Pública, após a intimação do réu do teor da r.sentence.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.